

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제02절 당사자의 자격>

[기출][2010-2-1]임의적 소송담당의 의의 및 유형, 허용 요건, 소송법적 효과

《【문제2】 다음 문제를 설명하시오.

(물음1) 임의적 소송담당(임의적 소송신탁) (25점)》

<문제2의 물음1> 임의적 소송담당의 의의 및 유형, 허용 요건, 소송법적 효과

I. 임의적 소송담당의 의의 및 유형

1. 의의

- 권리주체인 본인의 의사에 기초하여 제3자에게 소송수행권을 수여하는 경우를 말한다. 법률에 규정이 있는 경우뿐만 아니라, 법률에 규정이 없더라도 일정한 요건 하에 예외적으로 허용될 수 있다.

2. 유형

(1) 법률에 명문 규정이 있는 경우

- "민사소송법 제53조"의 선정당사자, 추심명령을 얻은 채권자 등이 대표적인 예이다. 선정당사자는 공동의 이해관계를 가진 다수의 사람 중 선출된 자가 전원을 위해 소송을 수행하는 제도이다.

(2) 법률에 명문 규정이 없는 경우

- 민법상 조합의 업무집행조합원이나 아파트 관리단 대표 등이 자신을 당사자로 하여 소송을 수행할 수 있는지가 문제된다. "판례"는 원칙적으로 부정하나 엄격한 요건 하에 긍정하고 있다.

II. 임의적 소송담당의 허용 요건

1. 원칙적 금지(소송신탁의 금지)

- "신탁법 제6조"는 소송행위를 하게 하는 것을 목적으로 하는 신탁을 금지하고 있다. 이는 변호사법 위반을 방지하고 소송상의 투기 행위를 막아 사법 제도의 건전성을 유지하기 위함이다.

2. 예외적 허용의 요건("판례"의 태도)

(1) 합리적 필요성

- 당사자가 직접 소송을 수행하는 것보다 제3자가 수행하는 것이 소송경제적으로 유리하거나, 권리 실현을 위해 불가피한 사정이 인정되어야 한다.

(2) 변호사대리 원칙 및 소송신탁 금지의 탈법 방지

- 소송담당을 허용하더라도 변호사법이 금지하는 대리 포섭이나 부당한 이익 취득의 위험이 없어야 한다. "판례"는 업무집행조합원이 조합재산에 관하여 조합원 전원을 위하여 소송을 수행하는 경우 등을 긍정한다.

(3) 명시적 권한 부여

- 본인으로부터 소송수행권 부여에 관한 명확한 의사가 있어야 하며, 이는 단순한 대리권 수여와 구별되는 당사자 지위의 부여여야 한다.

III. 소송법적 효과

1. 소송수행권의 이전

- 임의적 소송담당이 성립하면 소송담당자가 원고 또는 피고로서 당사자 지위를 갖는다. 이때 본인이 소송수행권을 잃는지 여부에 따라 병행적 소송담당과 갈음적 소송담당으로 나뉜다.

2. 판결의 효력 확장

- "민사소송법 제218조 제3항"에 따라 소송담당자가 받은 판결의 효력(기판력)은 권리주체인 본인에게도 미친다. 따라서 본인이 다시 동일한 소송을 제기하는 것은 기판력에 저촉된다.

3. 소송 비용의 부담

- 실제 소송을 수행한 소송담당자가 소송비용 부담의 주체가 되나, 본인 또한 판결의 효력을 받는 자로서 일정한 경우 비용 부담의 책임을 질 수 있다.

IV. 결론

- 임의적 소송담당은 당사자 적격의 예외로서 소송수행의 편의를 도모하는 유용한 제도이나, 무분별한 허용은 변호사법의 근간을 흔들 수 있다. 따라서 "판례"는 선정당사자처럼 법률이 정한 경우 외에는 업무집행조합원과 같이 실질적 이해관계를 같이하고 소송수행의 합리적 필요성이 인정되는 경우에만 극히 제한적으로 이를 인정하고 있다. 이는 사적 자치의 원칙과 사법 절차의 투명성 사이에서 균형을 맞추려는 사법부의 의지로 풀이된다.